

1505671-26.2020.8.26.0099

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/03/2022

... transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJ-SP 00003795520168260397 SP 0000379-55.2016.8.26.0397, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505671-26.2020.8.26.0099

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3084477/2020 - DEL.SEC.BRAG.PTA

PLANTÃO, 14166441 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO DO NASCIMENTO FERREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

DANILO DO NASCIMENTO FERREIRA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 16 de outubro de 2020, na rua Vicente Talamino, Uberaba, Vila Motta, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para consumo

peçoal, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 2,4 gramas, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Recebida a denúncia aos 11 de maio de 2021 (fl. 110), o acusado não foi localizado para citação peçoal, razão pela qual realizou sua citação por edital (fl. 111). Posteriormente, ele se fez representar nos autos (fl. 121) e apresentou sua resposta à acusação (fls. 126/129). Ratificado o recebimento da inicial (fl. 157), o feito seguiu o seu curso regular. Durante a instrução processual ouviu-se uma testemunha de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 174). Em seguida, as partes apresentaram alegações finais. A acusação requereu a procedência da ação para o fim de condenar o acusado nas penas do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006 (fl.174). A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante e a aplicação da pena de advertência (fl. 174).

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A materialidade do delito está plenamente comprovada. O laudo de exame químico toxicológico (fl. 55) descreveu e concluiu que a substância analisada é maconha, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas. Ademais, está evidente que o elemento responsável pelos efeitos farmacológicos da erva estava presente. Pelos testemunhos colhidos a autoria também se evidenciou. O acusado em seu interrogatório admitiu a posse da droga e a finalidade de uso próprio. O PM Danilo narrou que durante diligência efetuada na casa do acusado, apreendeu em seu poder uma porção de maconha. Questionado, ele admitiu que a droga era destinada ao seu consumo peçoal. Nada existe nos autos a demonstrar que os agentes responsáveis pela prisão do acusado tivessem qualquer motivo para imputar a ele, indevidamente, a prática de crime. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a autoria imputada. Logo, a confissão está em harmonia com as demais provas dos autos. Assim sendo, estão certas a autoria e a materialidade do crime contra a saúde pública. A quantidade da droga encontrada, o local e a forma como foi encontrado, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso próprio, pelo que, esta acusação merece prosperar. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06). PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que o crime de posse de drogas para consumo peçoal (art. 28 da Lei n. 11.343/06) é de perigo presumido ou abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância. 2. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 34466 DF 2012/0247691-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 14/05/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2013). POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. Apelo defensivo. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inocorrência. Dispositivo penal que tutela a saúde pública. Efeitos nocivos das substâncias entorpecentes. Vício, dependência, transtornos familiares e fomento ao tráfico de drogas. Materialidade de autoria bem comprovadas. Laudo pericial, termo circunstanciado e depoimento dos policiais responsáveis pela apreensão. Depoimento policial válido. Ausência de inconsistências e máculas nas declarações. Condenação mantida. Pena bem dosada. Apelo improvido. (TJ-SP 00003795520168260397 SP 0000379-55.2016.8.26.0397, Relator:

Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 19/12/2017, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/12/2017).

Outrossim, a alegação da defesa de inconstitucionalidade do art. 28 da lei nº 11.343/06 não deve prosperar, pois até a conclusão do julgamento do RE nº 635.659/SP pelo Supremo Tribunal Federal, o referido artigo permanece constitucional e com natureza jurídica de crime, o que permite a sua aplicação. A questão, inclusive, já foi analisada pelo Plenário da Suprema Corte quando do julgamento da Questão de Ordem suscitada nos autos do RE 430.105/RJ:

I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L.11.343/06): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L.11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto despreço do legislador pelo \rigor técnico\, que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado \Dos Crimes e das Penas\, só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão \reincidência\, também não se pode emprestar um sentido \popular\, especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de \despenalização\, entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art.30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE-QO 430105, Relator Min. Sepúlveda Pertence, 13/02/2007, Primeira Turma).

E ainda:

Porte de entorpecente (MACONHA) para uso próprio. Sentença absolutória pelas razões já expostas em votos proferidos no julgamento, ainda em curso, do RE 634.659/SP: norma do art. 28 da Lei de Drogas que seria inconstitucional na medida em que ofenderia diversos princípios, dentre os quais o da ofensividade e alteridade - Insurgência do Ministério Público - ACOLHIMENTO. Afastamento da tese de inconstitucionalidade, insignificância e de descriminalização (abolitio criminis). Perigo coletivo que não pode ser desconsiderado já que a conduta ajuda a difundir a droga no meio social e incentiva cadeia de crimes, notadamente o tráfico, que a Constituição Federal equiparou aos hediondos. Situação que inclusive se assemelha à da receptação quanto aos crimes patrimoniais que: (1) para uma teoria - adotada no Brasil - protege de forma autônoma o bem jurídico atacado com a transgressão anterior; (2) para outra corrente - adotada na França - configura uma forma de cumplicidade com quem pratica o crime anterior. Fundamento para punição bastante evidente em ambas as concepções. Princípio da alteridade que não é desrespeitado, sendo enganosa a comparação da punição com base no art. 28 da lei de tóxicos com a que se levasse a efeito pela tentativa de suicídio e auto-lesão. Enfoque correto: assim como não se pune só o uso da droga também não se pune só o atentado contra a própria vida ou incolumidade física. Coibindo-se, porém, o porte ilegal da droga, com que se periclita a saúde pública; e o porte ilegal da arma, com o qual se coloca em risco a incolumidade pública. Jurisprudência da 5ª e 6ª Turmas do STJ reconhecendo o perigo abstrato à saúde pública e afastando a tese da insignificância. Crime, ademais, de efeito cumulativo, sendo a reduzida quantidade de droga da essência do próprio tipo (art. 28), até para distingui-lo do art. 33. Constitucionalidade da criminalização da posse de drogas para uso próprio e da

inclusão da cannabis no rol de substâncias proscritas. Inteligência da legislação ordinária (art. 16 da lei 6.368/76, sucedido pelo art. 28 da lei 11.343/06 - princípio da continuidade normativo-típica) no âmbito dos art. 196 e 5º, XLIII, da Constituição Federal e da Convenção de Viena de 1988 (internalizada pelo Decreto nº 154 de 26 de junho de 1991) que já à ocasião recomendava que: 1) os Estados Nacionais coibissem penalmente o cultivo não só de sementes de ópio e do arbusto da coca, como também da planta da cannabis (art. 1, inc. II); 2) tais Estados Nacionais caracterizassem como crime ainda que só a posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 2). RE 635.659/SP que apesar da repercussão geral ainda não foi julgado, o que faz prevalecer lei vigente (art. 28 da 11.343/06) de constitucionalidade já afirmada no RE 430.105/RJ de fevereiro de 2007 e repercutida pelo FONAJE: ENUNCIADO 94 - "A Lei nº 11.343/2006 não descriminalizou a conduta de posse ilegal de drogas para uso próprio" (XXI Encontro - Vitória/ES). ENUNCIADO 82 - "O autor do fato previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 deverá ser encaminhado à autoridade policial para as providências do art. 48, § 2º da mesma Lei" (XX Encontro - São Paulo/SP). Vedação, ao intérprete, de sobrepor seu critério de proporcionalidade ou razoabilidade ao do legislador. Mormente em matéria tradicionalmente positivada e cuja necessidade de alteração não é produto de consenso, como se extrai da consulta à opinião pública e ao DIREITO COMPARADO. Interpretação autêntica (vontade do legislador) - relatório apresentado pelo Deputado Paulo Pimenta, Relator do Projeto de Lei 7.134/02 oriundo do Senado e que culminou na atual lei de Tóxicos: "Ressalvamos que não estamos, de forma alguma, descriminalizando a conduta do usuário - o Brasil é, inclusive, signatário de convenções internacionais que proíbem a eliminação desse delito. O que fazemos é apenas modificar os tipos penais a serem aplicados ao usuário, excluindo a privação da liberdade, como pena principal". Recurso provido com a consequente condenação do apelado que, por ser reincidente (anterior condenação por tráfico de entorpecentes), deve cumprir, na forma do art. 28, II, da Lei 11.343/06, 4 (quatro) meses de prestação de serviços comunitários.(TJ-SP - APR: 00010759520178260352 SP 0001075-95.2017.8.26.0352, Relator: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 21/08/2020, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/08/2020)

Na mesma linha, cabe destacar que o princípio da insignificância não pode ser aplicado ao delito previsto no art. 28 da lei nº 11.343/06, pois se trata de infração de perigo abstrato em que o bem jurídico tutelado é a saúde pública (e não do indivíduo), o que deve ser reprimido.

Eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL - TÓXICOS - POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - ALEGAÇÃO DE AUTO LESÃO - AUSÊNCIA DE PROVA - Impossível a absolvição do crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, pela aplicação do princípio da insignificância, pois, em se tratando de crime de perigo abstrato, que tem como bem jurídico tutelado não apenas a saúde do usuário, mas também a saúde pública, revela-se irrelevante a quantidade de substância entorpecente apreendida.2) Não se trata de incriminar alguém por autolesão, pois a criminalização da conduta disposta no art. 28, da Lei de Tóxicos possui como bem jurídico protegido pela norma penal incriminadora a saúde pública. 3) Validade do depoimento do guarda municipal desde que não infirmado por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida.(TJ-SP - APR: 00000682520168260022 SP 0000068-25.2016.8.26.0022, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 23/04/2018, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 25/04/2018)

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelo condenado não justifica aumento na pena base. Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 47/49. Sua conduta social e personalidade não podem ser avaliadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não justificam maior

reprovação.

Presente a circunstância mencionada, suas penas serão fixadas acima do mínimo legal.

Na segunda fase, certificada a reincidência do condenado à fl. 46, observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas.

Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram detectadas.

Em virtude das circunstâncias em que ocorreram os fatos, o Juízo entende ser insuficiente para o caso a aplicação de advertência, motivo pelo qual outra será a sanção imposta, a teor do artigo 28, de referida legislação.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR DANILO DO NASCIMENTO FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, "caput", da Lei 11.343/2006, à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUÍTOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 10 meses, na forma dos §§ 3º a 5º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução.

Facultado o recurso em liberdade haja vista que o sentenciado respondeu ao processo nesta condição e, nestes autos, não se avistam como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se.

Bragança Paulista, 02 de março de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA